

1500764-72.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... da ré estivesse sendo ameaçado, a prática do tráfico não se justificaria e não era a única conduta possível a ser adotada. Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Confissão em harmonia com o restante do quadro probatório. Alegações de crime impossível, inexigibilidade de conduta diversa e estado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500764-72.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500764-72.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELE MARGARIDA DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ANA CAROLINA DO CARMO FRANÇA e MICHELE MARGARIDA DE SOUZA foram denunciadas por incursão no caput art. 33 c/c inciso II do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 17 de abril de 2022, por volta das 10h40min, na Avenida Papa João Paulo XXIII, 3905, Centro de Detenção Provisória de Mauá, Reg. Planejamento 2, nesta cidade de Mauá, as acusadas traziam consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, para fins de tráfico, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 30-1, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, as rés foram citadas (fls. 116 e 128) e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório das rés.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa suscita a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls. 134-41).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-3), boletim de ocorrência (fls. 04-7), auto de exibição e apreensão (fls. 30-1), laudos de constatação (fls. 34-41) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 88-90 e 108-10).

Comprovou-se a autoria.

As rés foram devidamente interrogadas em solo policial e em juízo (fls. 12 e 21 e mídia digital).

Os agentes penitenciários, na fase administrativa, historiaram que: (sic) "exercia suas funções no Centro de Detenção Provisória de Mauá, sendo que na ocasião custodiados do local recebiam visitas de familiares. Assim, apresentaram-se para a visita Ana Carolina do Carmo França e Michele Margarida de Souza. Antes de ingressarem no estabelecimento prisional, foram submetidas a revista íntima nos termos da legislação vigente. Durante o procedimento foram encontrados pela depoente no interior da calcinha de Ana Carolina dois tabletes de Haxixe prensado. No procedimento ao qual se submeteu Michele Margarida de Souza, foram encontradas novamente pela depoente no interior de sua calcinha três cartelas que aparentavam LSD. Ante as evidências, nada restou às ora indiciadas senão confessarem que pretendiam ingressar no referido Centro de Detenção Provisória em poder das referidas drogas visando entregá-las para os detentos que lá estão custodiados. As indiciadas não chegaram ao local juntas e não visitariam a mesma pessoa" (fls. 10-1).

Sob o contraditório, a agente penitenciária Maria reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido e confirmou ter localizado as drogas no interior da roupa íntima das rés. Informalmente, elas admitiram que levariam as drogas para os detentos (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de agentes penitenciários não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos agentes penitenciários. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

As circunstâncias da apreensão, tais como a forma e o local em que eram transportadas, trazem elementos suficientes de que as acusadas tinham a droga para entrega a terceiros, detidos no estabelecimento prisional.

Também, parece-me evidente que não se trata de crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, consumou-se antes de as acusadas ingressarem no estabelecimento prisional. É certo, ainda, que esse modo de agir é, infelizmente, comum e competente para o ingresso de drogas nos presídios. Registre-se, também, que as drogas somente foram localizadas após as rés terem sido submetidas à revista em sala própria. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CONSUMADO. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO ENTORPECENTES NO INTERIOR DAS CAVIDADES NATURAIS. TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES. OFENSA AOS ARTS. 317 E 318, V, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.659.418/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020 - grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. 6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio. [...] 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018 - grifo nosso).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FISCALIZATÓRIAS E FUNDADA SUSPEITA DE QUE A RÉ TRANSPORTAVA DROGAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVA LÍCITA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A revista íntima no estabelecimento prisional, por se tratar de atividade humana, sujeita a falhas, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito de tráfico de drogas, ou seja, a entrada do entorpecente no estabelecimento prisional, sendo, portanto, típica a conduta praticada pela recorrente. Precedentes. 4. Habeas corpus

não conhecido. (HC 381.593/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017 -grifo nosso).

Do mesmo modo, a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, notadamente quanto à ré Michele, não merece acolhida. A versão apresentada pela acusada de que seu marido, ameaçado no interior do presídio, pediu que levasse o entorpecente, encontra-se dissociada dos demais elementos de provas. Além disso, ainda que o marido da ré estivesse sendo ameaçado, a prática do tráfico não se justificaria e não era a única conduta possível a ser adotada. Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Confissão em harmonia com o restante do quadro probatório. Alegações de crime impossível, inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade. Inocorrência. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, inafastável. Condenação mantida. Penas-base no piso, com acréscimo mínimo pela majorante e aplicação do redutor máximo do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Mitigado, no entanto, o regime prisional para o inicial semiaberto, por conta da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n 596.603-SP, relacionado ao denominado "tráfico privilegiado". Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido, para o fim mencionado. (TJSP; Apelação Criminal 1502564-52.2019.8.26.0537; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020).

Dessa forma, entendo que os delitos de tráfico de drogas estão fartamente comprovados.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, as penas devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, ausente qualquer circunstância judicial desfavorável.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi presa em flagrante, no interior do estabelecimento prisional, em poder dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório das rés, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena

execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisor, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.N.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54).Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Ainda assim, as penas não poderiam ser conduzidas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa da dosimetria, evidenciado que as drogas apreendidas destinavam-se à entrega de detentos do Centro de Detenção Provisória de Mauá, com espeque no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06, majoram-se as penas em 1/6, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda nesta fase, verifico que a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 está caracterizada, razão pela qual reduzo a pena das rés em 3/5, considerando-se o potencial lesivo das drogas apreendidas (haxixe e LSD), totalizando 02 anos de reclusão e 04 meses de reclusão e 233 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica das rés.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, considerando a gravidade in concreto do delito, notadamente pela natureza dos entorpecentes apreendidos, a forma como foram transportados, o ajuste prévio com os respectivos maridos que receberiam as drogas, além da audácia de praticar o delito nas dependências de local altamente vigiado, em total desrespeito às instituições estatais, indicam um grau acentuado de culpabilidade. Nesses termos, em atenção ao entendimento do c. STJ no HC n. 596.603, o regime inicial semiaberto mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

No mais, deve ser pontuado que o crime de tráfico demanda uma resposta estatal incisiva, sem o que não seria reprovado adequadamente pela ordem jurídica, ante as nefastas consequências à saúde pública, num panorama que representaria um estímulo ao cometimento de futuras infrações penais.

Nessa linha, destaca-se acórdão do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06). Tráfico de entorpecentes agravado, nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da Lei de Tóxicos), com reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento da droga, aliado às circunstâncias da prisão, que revelam o intuito de tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciárias. Confissão judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento mantido. Regime inicial semiaberto adequado à hipótese. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido, com expedição de mandado de prisão. "[...] No que diz ao regime, o regime semiaberto fixado pela origem é de ser mantido, sendo incabível a fixação de regime mais branco, como quer a Defesa. Face ao disposto no art. 33, §3º, do Cód. Penal, em atenção à natureza gravíssima do delito praticado e suas circunstâncias, envolvendo a distribuição de entorpecentes em pleno estabelecimento prisional, local destinado ao cumprimento de penas em regime fechado. Ora, ainda que primária a acusada, a gravidade concreta dos fatos praticados desabilita concessão de regime inicial aberto, como acertadamente fundamentado pelo Magistrado de piso: "Vislumbro a necessidade de a ré iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado nas dependências de

estabelecimento prisional, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, sua conduta de traficar drogas enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na saúde pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa sociedade. Não bastasse isto, impõe-se a ré uma resposta estatal adequada até mesmo para que se sinta desestimulada a prosseguir por este caminho, tudo em observância à função preventiva especial da pena" (f. 161 g.n.). Tudo a revelar, portanto e enfim, que o narcotráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, "data venia". Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que se sujeita, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas é um delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Portanto, aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Daí porque o regime inicial semiaberto é de ser mantido. [...]"

(TJSP; Apelação Criminal 0000620-21.2018.8.26.0571; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis ou de qualquer outro benefício, insuficientes para prevenção e reprovação das condutas.

Posto isso, PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR as rés ANA CAROLINA DO CARMO FRANÇA e MICHELE MARGARIDA DE SOUZA, qualificadas nos autos, a cumprir pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar 233 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no § 4º do art. 33 c/c inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

Faculta-se às acusadas o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome das rés no rol dos culpados e oficie-se para a incineração das drogas apreendidas (fls. 30-1), nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 188).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA